

共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲及び乙は、強盗を共謀し、甲がA方の外で見張りをしている間に乙がA方に侵入したが、犯行の発覚を恐れた甲が、乙に対して電話で「人が集まっているから、早く止めた方がいい。俺は先に帰る。」と告げてその場から逃走した。乙は、甲の逃走を認識したが、A方内においてAに暴行を加えて現金を強取した。乙が強盗行為に着手する前に甲の逃走を認識した以上、甲及び乙に強盗罪の共同正犯は成立しない。
2. 甲及び乙は、危険な作業を共同して行う過程において、Aが負傷する事故を防止するための共同の業務上の注意義務に共同して違反し、Aに傷害を負わせた。甲と乙の間にAの傷害発生についての共謀がなかった以上、甲及び乙に業務上過失致傷罪の共同正犯は成立しない。
3. 甲は、乙からAを殺害するための毒物の入手を頼まれ、入手した毒物を乙に渡したが、結局、乙は、これを用いず、Aに睡眠薬を服用させた上でAを絞殺した。甲が乙に渡した毒物が利用されていないので、甲に殺人予備罪の共同正犯は成立しない。
4. 甲は、乙がホテルの一室において賭博場を開張して利得を得るつもりであることを知りながら、乙のためにA及びBを同室に誘い、賭博をさせた。甲と乙との間に意思連絡がなくとも、甲に賭博場開張図利罪の幫助犯が成立する。
5. 甲は、劇場の責任者の立場にあったが、出演者乙の公然わいせつ行為を目撃しながら、乙に軽く注意をしたものの、公演を止めず、同行為の継続を容易にした。甲が乙に注意をした以上、甲に公然わいせつ罪の共犯は成立しない。

1 誤っている

最決平 21.6.30 (百選 I 97 事件) は、本記述と類似の事案において、被告人が結果防止措置を講じていないことを理由に当初の共謀関係の解消を否定して、被告人に強盗致傷罪の共同正犯の成立を認めている。よって、本記述においては、甲に共犯関係の解消が認められないため、強盗罪の共同正犯が成立する。

2 誤っている

最判昭 28.1.23 は、要件は必ずしも明らかではないものの、過失犯の共同正犯を認めている。そして、上記判例と同じく過失犯の共同正犯を認めた裁判例 (東京地判平 4.1.23) は、「本件のごとく、社会生活上危険かつ重大な結果の発生することが予想される場合においては、相互利用・補充による共同の注意義務を負う共同作業者が現に存在するところであり、しかもその共同作業者間において、その注意義務を怠った共同の行為があると認められる場合には、その共同作業者全員に対し過失犯の共同正犯の成立を認めた上、発生した結果全体につき共同正犯者としての刑事責任を負わしめることは、なんら刑法上の責任主義に反するものではないと思考する」ということを挙げている。よって、本記述においては、甲及び乙は共同の業務上の注意義務に共同して違反しているから、甲及び乙に業務上過失致傷罪の共同正犯が成立する。

3 誤っている

最決昭 37.11.8 (百選 I 80 事件) は、本記述と類似の事案において、殺人予備罪の共同正犯が成立するとしている。よって、本記述においては、甲には殺人予備罪の共同正犯が成立する。

4 正しい

大判大 14.1.22 は、本記述と類似の事案において、正犯者が幫助者の行為を認識する必要がないことを明示し、片面的幫助の成立可能性を肯定している。本記述においては、甲と乙との間に意思連絡がないが、客を賭博場に誘い賭博をさせることで、乙が賭博場を開張し客から利益を得ることを容易にしているの、物理的幫助が認められ、甲に賭博場開張図利罪の幫助犯が成立する。

5 誤っている

最判昭 29.3.2 は、本記述と同様の事案において、公然わいせつ罪の幫助犯が成立するとしている。よって、本記述においては、劇場の責任者である甲は乙に軽く注意をしたものの、公演を止めず、乙の公然わいせつ行為の継続を容易にしているから、甲に公然わいせつ罪の共犯が成立する。